

1500634-91.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500634-91.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-91.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2087953/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kaique da Silva Custodio

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA HELENA HEHL FORJAZ DE TOLEDO

Vistos.

KAÍQUE DA SILVA CUSTÓDIO, qualificado às fls. 10/12, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 30 de março de 2022, por volta das 20h15, na Avenida Nossa Senhora das Graças, altura do nº 400, bairro do Serraria, nesta Comarca de Diadema, atuando previamente ajustado com indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Diógenes Pacheco Leal de Oliveira, subtraiu para eles, um aparelho celular, uma mochila contendo uma carteira, valores e outros pertences pessoais, bem como a motocicleta YAMAHA/MT03, de placas FFS-1J25, avaliada em R\$ 20.000,00 (fls. 22). Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 31/34). A denúncia foi recebida em 13/04/2022 (fl. 57). Citado (fl. 72), a defesa inicial encontra-se as fl. 76/77, feita pelo d. Defensor Público nomeado. Em audiência una foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pelas Partes e

interrogado o réu.

Em debates orais, o d. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o duplo aumento pelas duas majorantes, sem se falar em confissão e sem se considerar o crime em sua forma tentada, pedindo pelo regime fechado, e sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem do recurso em liberdade.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória, ou a desclassificação para a tentativa. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, reduzida pela atenuante da confissão, e pela tentença, fixando-se o regime semiaberto, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/20, auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 08, auto de reconhecimento da arma de fogo a fl. 09, auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fl. 21).

Ressalto que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída e em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório. (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66)

A autoria é inconteste.

A vítima Diógenes Pacheco Leal de Oliveira, ouvida em solo policial (fl. 06), declarou que conduzia a motocicleta Yamaha MT 03, Placas FFS1J25 de um amigo pelo local dos fatos, momento no qual foi abordado por dois indivíduos desconhecidos numa moto. Um dos autores, exibindo uma de fogo, anunciou o assalto exigindo-lhe que entregasse os seus bens. Os roubadores passaram a subtrair-lhe seu celular, mochila, dinheiro e carteira. Um dos autores subiu na moto, enquanto o outro procurava por outros pertences em seus bolsos. Posteriormente, os policiais encostaram e os roubadores correram. Durante a corrida, seus pertences foram caindo ao chão, razão pela qual os recolheu, não havendo nenhuma perda patrimonial. Reconheceu o indiciado Kaique da Silva Custódio com um dos autores do roubo, sendo ele o indivíduo que desceu da moto exibindo uma arma de fogo. Esclareceu que o indivíduo que conseguiu se evadir era de cor branca, alto, magro.

Neste sentido foram as declarações da vítima em solo judicial reiterando que saiu do trabalho e ao passar na lombada, ao desacelerar, dois indivíduos encostaram, um lhe puxou e anunciou o assalto. O réu lhe abordou com a arma, subtraiu seus pertences, e o outro pegou sua moto. Como seu celular estava dentro da jaqueta, tiveram dificuldade de pegar o aparelho e ameaçaram de morte. Então disse que ajudaria e retirou o casaco, quando os policiais chegaram e os dois indivíduos jogaram as motos no chão e se evadiram, e só o réu foi detido. Pegou suas coisas que o réu foi jogando no chão, recuperando tudo, embora o capacete tenha quebrado e a moto ficou arranhada. Reconheceu o réu com certeza. A arma de fogo estava com o réu e ele desembarcou da moto e pegou suas coisas. O tempo todo o réu ficou com a arma apontada para si e disseram que iam atirar se não entregasse o celular que estava por dentro da jaqueta. Kaique é mais moreno escuro, lábios grandes, aparentando ser um pouco mais baixo do que a vítima, com aproximadamente trinta anos de idade, não era novinho não. Reconhece o réu que está com o numero 2. Às reperguntas disse que o réu ainda estava consigo, pegando seus pertences, quando os policiais chegaram.

Os policiais militares Flavio Augusto Moreira dos Santos e Cleiton Izidro Leocadio, ouvidos extrajudicialmente (fls. 04 e 05), informaram que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, com o uso da viatura M24306, quando avistaram dois indivíduos em atos executórios de crime de roubo contra uma vítima pelo local, com o intuito de subtrair-lhe a motocicleta YAMAHA MT 03, placas FFS1J25. Imediatamente, deram voz de parada. Contudo, ao avistarem os policiais, os roubadores abandonaram a motocicleta Yamaha, ostentando emplacamento EKC8181 utilizada para o roubo e

empreenderam fuga. Lograram êxito em impedir a fuga de um dos dois indivíduos, identificado como Kaíque da Silva Custódio. Em busca pessoal, identificaram um revólver, tipo revólver, calibre 32, com a numeração raspada, com três munições íntegras, na cintura dele. Verificando os sinais identificadores do veículo utilizado pelos autores, identificaram que o chassi aparentava estar com sinais suprimidos. Pelo local a vítima Diógenes Pacheco Leal de Oliveira identificou os objetos que caíram ao solo com a tentativa de fuga do autor que conseguiram capturar, sendo que a vítima já ficou em posse dos seus pertences, inclusive a motocicleta. Não obstante, identificaram um celular Motorola pelo chão, possivelmente pertencendo ao outro roubador que conseguiu se evadir. Esclareceu que o autor que conseguiu fugir tinha aproximadamente 1,85m, cútis branca, compleição magra.

Perante ao Juiz imparcial, o policial Flavio Moreira disse que estavam em patrulhamento pela via quando avistaram três pessoas em posse de motocicletas e acharam as atitudes suspeitas, e carros informaram que estava ocorrendo um roubo. A equipe se aproximou e presenciou dois indivíduos puxando, agarrando a bolsa transpassada em outro rapaz. Desembarcaram e foi dada voz de parada. O réu e o ouro meliante ao visualizaram os policiais, empurraram a vítima e correram. Correu atrás deles e viu o réu jogar um celular e um objeto prata que aparentava ser uma arma de fogo. Ele escorregou na via e então conseguiu detê-lo, sendo que ele ainda tentou se esquivar, mas foi algemado. Seu colega chegou com a viatura e outras viaturas também vieram no apoio. Questionado, informalmente confessou o roubo e na calçada estava um aparelho telefônico do parceiro do réu, e a vítima reconheceu a foto que estava no aparelho e que seria do outro roubador. Apreenderam um revólver calibre 32, municiado, que foi dispensado pelo acusado. A vítima disse que o réu foi bem agressivo e batia no peito dele para ir mais rápido ao entregar os bens. Reconhece o acusado. Viu inicialmente a vítima ainda em cima da moto e os meliantes puxando a bolsa dela.

Em juízo o policial Cleiton asseverou que estavam em patrulhamento e avistou três indivíduos amontoados, dois deles tentando puxar pertences do terceiro. Carros indicaram que estaria havendo roubo ali. Na tentativa de abordagem, dois se evadiram. Um foi perseguido por seu parceiro e logo após abordado. Chegou no apoio e soube que ele havia jogado objetos pela via, um celular e uma arma de fogo calibre 32, com três munições. O réu foi preso e relatou ali mesmo que estava praticando o roubo por ter pendências, e a vítima também informou que o réu estava agressivo e puxava seus objetos. Ficaram caídas as motos e os capacetes, e a vítima estava ao lado da moto. Reconhece o réu e segundo a vítima, foi ele quem a ameaçou com a arma de fogo.

O indiciado, em solo pré-processual (fl. 12), declarou que em data anterior pedira um dinheiro emprestado para pessoa que conhece apenas por "BUG" com o objetivo de pagar a pensão dos seus filhos. Tendo em vista que estava com dificuldades de pagar a dívida, a pessoa de "BUG" afirmou que se ele não pagasse a dívida ele iria "acabar com a vida" do interrogado. Diante disso, BUG exigiu-lhe que prestasse um serviço levando um amigo dele para onde ele o guiasse com sua moto. Em razão disso, atendeu ao exigido por "BUG" e levou a pessoa que estava com ele, o qual o indicava quais caminhos seguir. Em um dado momento, a pessoa que ele levava ordenou-lhe que parasse a moto, momento no qual desembarcou e anunciou o assalto contra a vítima. Afirmou que apenas naquele momento se deu conta de que iria prestar serviço para um roubo. Quando percebeu os fatos, tentou sair com a moto, mas não conseguiu ligá-la. Pouco tempo depois os policiais militares chegaram e correu. Afirmou que a moto que usaram era dele, comprada por meio de Facebook, cuja origem é de um leilão. Declarou que não esteve em posse da arma de fogo utilizada.

Sob o crivo do contraditório, o réu alegou que estava no horário de trabalho como pintor de dia e pizzaiolo à noite. Foi para casa pegar roupa e dinheiro. Deu uma carona para um rapaz, a quem conhece por "Felipe", em troca de vinte reais de gasolina. Perguntou se ele tinha algo de errado. Respondeu que não. Sua moto morreu, e na terceira vez, ele pulou da moto e abordou a vítima. Tentou fazer sua moto ligar para sair dali, e não conseguiu. Daí ele subiu na moto, e depois desceu

e correu. Não correu e não sabia que o rapaz estava armado. Tem filho, paga aluguel, tem dívida, mas nunca pegou em arma e nem roubou. Não tem passagem policial. Acredita que está caindo tudo em cima de si porque os policiais não pegaram o outro rapaz. Não confessou o roubo aos policiais, disse a eles que estava em horário de serviço.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pelas declarações da vítima, quer pelo reconhecimento pessoal positivo feito pela vítima tanto concernente a um dos autores do roubo, quanto ao armamento por ele utilizado, tudo embasado pelos relatos dos policiais, presenciais da parte final do roubo, e sem prova contrária ou favorável ao acusado, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura. Perscrutando os depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima, ambos foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi do acusado, a forma como foi abordada, sendo cercado por dois indivíduos, um deles o réu, reconhecido com segurança e certeza tanto em solo policial (fl. 08) como em juízo. Os meliantes se valeram de uma motocicleta, e sob grave ameaça exercida com apresentação da arma de fogo, apreendida, reconhecida pela vítima em ambas as fases da persecução penal (fl. 09) e periciada (fls. 107/108 e 121), foi subjugada, e assim, reduzida qualquer esfera de defesa de seu patrimônio.

A declaração da vítima, ainda, deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, as palavras da ofendida revelaram-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios, já não bastasse os relatos dos milicianos, presenciais do crime.

Ressalto que: em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir. (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021).

Os depoimentos dos policiais militares também se revelaram coesos e harmônicos em ambas as fases que fora inquiridos, pois bem demonstrados que após visualização de dois indivíduos em atos executórias de roubo em desfavor do ofendido, iniciaram uma abordagem, dando causa a uma breve perseguição que culminou com fuga à pé dos meliantes, concluindo a diligência na prisão apenas do réu, e na apreensão da motocicleta produto de roubo e por eles utilizada na empreitada criminoso, assim como do armamento usado no crime.

Os agentes públicos de segurança sequer conheciam o acusado a lhe imputar indevidamente um crime tão grave, razão pela qual os seus depoimentos têm valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais. (RJDTACRIM 42/215).

Como visto, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado. A captura somente foi possível pela firme disposição dos policiais no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação.

O concurso de agentes ficou devidamente esquadrinhado através das palavras do ofendido em consonância com os relatos dos milicianos que presenciaram o réu e seu comparsa roubando a vítima, demonstrando claramente que os agentes estavam conluídos para a prática das condutas, ante a clara divisão de tarefas, tendo o condutor da motocicleta aguardado para efetuar a fuga, e o garupa exercido a função de realizar a abordagem nefasta de exercer a grave ameaça, em posse da arma de fogo, apresentando a vítima a fim de concretizar a conduta delitiva com êxito. A arma de fogo apreendida na posse do acusado se apresentava apta para a realização de disparos, nos termos do laudo pericial de fls. 107/108 e 121, e municiada com três projéteis. E ela foi usada na prática delitiva, pelo réu, tanto que foi ele quem a dispensou como visualizado pelo policial.

Malgrado a aludida versão exculpatória do réu, desprovida de qualquer elemento probatório, restou frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

O réu, que se aventurou alegar, não empreendeu esforços para demonstrar o alegado álibi, haja vista que informou ter apenas conduzido a motocicleta dando carona a uma pessoa, conhecida por "Felipe", à quem perguntou se estava tudo bem, se ele não trazia nada ilícito com ele, o que não é comum de se questionar a alguém a quem vai se dar uma carona se não desconfiar de sua má índole, quer por alegar haver uma dívida a ser paga senão morreria, como dito em solo policial, ou quer porque o rapaz colocaria vinte reais de gasolina e por isso lhe deu carona, o que em si indica contradições em suas versões pouco críveis, sendo que nada disso foi provado, quer que desconhecesse o fato de que o rapaz estaria armado e que praticaria um roubo, até porque entrou em contradição a respeito do rapaz ter desembarcado, se quando ele mandou parar, ou se quando a moto morreu pela terceira vez. Nem há prova de que o réu tenha tentado fugir ao perceber que um crime estava em andamento. Ora, como visto, não trouxe aos autos prova de nada disso, nem que estivesse em horário de trabalho, nem com a pensão alimentícia atrasada, nem que apenas dava carona à troco de gasolina, nem seu desconhecimento de que estava participando de um roubo, nem de que não conseguiu fugir, até porque tão pouco tentou impedir que o crime se consumasse, ou seja, se de boa fé, deveria ter descido da moto e impedido o tal "Felipe" de roubar a vítima ou ser no mínimo solidário com ela.

Tem-se que o ônus da prova de quem alega compete a si, nos termos do que disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: TJSC: Quem afirma o álibi deve comprová-lo sob pena de não o fazendo, ser nenhum o valor probatório da negativa de autoria (JCAT 59/288-9). E: TACRSP - Prova. Álibi. Inexistência de comprovação da escusa oferecida pelo réu, preso em flagrante. Fato que autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação lançada pela Justiça Pública (...) Quem oferece álibi e não comprova, autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação contra si lançada pela Justiça Pública. A conclusão ainda se reforça quanto menos se mostre plausível a escusa oferecida pelo réu para a comprometedor situação em que se viu preso em flagrante (RT 747/692), in Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. São Paulo. Atlas. 8ª edição. p. 412.

Ademais, o contexto probatório indica que era o réu quem estava armado e que foi ele quem efetivamente desembarcou da moto e abordou e ameaçou a vítima com uma arma de fogo e anúncio de assalto por ele dado, caindo por terra, portanto, sua alegação de que apenas teria conduzido a moto e que teria tentado se evadir quando percebeu que o garupa praticava um crime, não procedendo sua tentativa de fazer parecer ter prestado menor participação no roubo ao não ter com ele anuído. Leia-se nesses termos: O transporte dos autores do crime não configura participação de menor importância (RJDTACrimSP, 03/78). Pelo contrário, segundo a vítima, o acusado foi quem praticou mais atos executórios e violentos.

Tem-se então que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia, bem como o dolo e as duas majorantes, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória

nem em desclassificação para a tentativa, uma vez que a grave ameaça foi praticada, havendo ainda a inversão da posse dos bens, que só foram recuperados ante a pronta intervenção policial, mas com prejuízo patrimonial à vítima, quem teve seu capacete quebrado e sua moto arranhada, já que os meliantes se desfizeram desses bens, os quais já haviam se apoderado, ao fugirem.

Nesse sentido, vide: Súmula 582 – STJ- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, de rigor a condenação.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais que reputo negativas, especialmente pelo prejuízo patrimonial à vítima e pela maior violência empreendida pelo réu com ameaça de morte, e o puxão da vítima ainda em andamento e em cima da moto, e pois, maior a reprovabilidade da conduta do réu, donde fixo em primeira fase a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a se considerar, de modo que inalterada a pena nessa etapa. E nem se alegue ter o réu confessado informalmente o crime, pois nem em solo policial e nem nessa audiência ele confirmou ter roubado a vítima, de modo que não demonstrou arrependimento e sequer colaborou com a busca da verdade real. Ademais, em nenhum momento sua confissão informal foi mencionada a embasar a condenação, até porque não reiterada pelo réu. E mais, a mentira que trouxe aos autos seria passível de aumento da pena-base, como parte da jurisprudência já vem acolhendo.

Em terceira fase, presentes duas causas de aumento da reprimenda - do concurso de agentes e a do emprego de arma de fogo. No caso dos autos, opto pela aplicação cumulativa delas dado às particularidades do caso concreto, eis que o roubo foi praticado por dois agentes, mas foi o acusado quem praticou todos os atos executórios do crime, e era ele, ainda, quem estava armado e apontou o armamento municiado com três projéteis, a causar maior risco de morte à vítima, e quem ameaçou de atirar contra ela, e quem puxou sua bolsa, enquanto seu comparsa lhe dava guarida e mais intimidava o ofendido impedindo chance de defesa, o que foi decisivo para o sucesso da empreitada criminoso, de modo a reclamar maior resposta penal, com a consideração individualizada de cada uma delas, e maior participação do acusado na empreitada criminoso.

Nesse sentido: (...) Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de concurso. Ademais, com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a 1/2 e, no §2ºA, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo. Nessa medida, estando as duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) devidamente demonstradas nos autos, sopesadas dentro dos parâmetros legais vigentes, devem ser mantidas.

(...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1501107-62.2020.8.26.0597, Relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso, Terceira Câmara de Direito Criminal, j. 29.03.2021). Assim, a sanção individualizada deve inicialmente ser majorada de 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas alcançando 06 anos de reclusão e 14 dias-multa. Na sequência, presente ainda a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inc. I, do art. 157, do Código Penal, por se tratar de causa de aumento de origem distinta da anterior, a elevação será sucessiva, de modo a incidir o acréscimo de 2/3 (dois terços), com a reprimenda alcançando 10 anos de reclusão e 23 dias-multa.

O crime de roubo se consumou. Ele apenas não se exauriu, o que difere de uma

tentativa. Assim, afastada a tese do conatus como já visto, e ausente causa de redução da pena. Veja: Consuma-se o roubo quando se pratica a violência, independentemente de efetiva subtração ou recuperação imediata da res. Jurisprudência pacífica da Suprema Corte e de outros Tribunais brasileiros (Ap. 966.461-1 e 1.001.003-8, ambas de São Paulo). E foi justamente o que ocorreu na presente hipótese, em que houve a inversão da posse do capacete e da moto, que foram jogados ao chão pelos meliantes antes da fuga.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena, a gravidade delitiva e a periculosidade do agente que efetivamente se armou e juntamente com o comparsa roubaram a vítima, com emprego de violência inclusive, fixo o regime prisional fechado. Incabível um mais brando, até porque as circunstâncias judiciais são negativas.

Acerca do tema é a jurisprudência dominante que sigo expondo: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada (JUTACRIMSP 91/117).

E mais: Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temibilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no início de cumprimento da pena, ou seja, regime prisional fechado (TACRIM, Ap. 918.023/1 – SP, 2ª Câmara, rel. Ricardo Lewandowski

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, não sendo suficiente nem eficaz à reprovação da conduta nem à ressocialização do agente, além de ausente o requisito objetivo, qual seja, a quantidade da reprimenda supera os quatro anos máximos permitidos.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal.

Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado mediante decretação de prisão preventiva, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. E o réu está preso há menos de seis meses, sem direito sequer à progressão de regime.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação

da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração .Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano ante ausência do quantum do prejuízo patrimonial à vítima, que poderá ser pleiteado junto ao juízo cível, por aquela.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra KAÍQUE DA SILVA CUSTÓDIO, qualificado às fls. 10/12, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e o faço para condena-lo à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere em que está.

Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa.

Comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA